MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA

REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 E SECUNDÁRIA DE PAREDES DE COURA – 16/16_E

Relatório Final
(de acordo com o artigo 148º do CCP)

Aos treze dias do mês de setembro de 2016 reuniu o Júri do Procedimento, nomeado em 11/07/2016 por deliberação da Câmara Municipal de Paredes de Coura, composto por Marlene Sofia Vieira Castilho, Sofia Lages Carvalho e Jorge Paulo Alvarenga Lages (suplente) para a elaboração do presente Relatório Final, ponderando as observações dos concorrentes em sede de audiência prévia.

De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 123º do CCP, aplicável por força do art.º 147.º do mesmo diploma, o Júri do Procedimento procedeu à audiência prévia escrita dos concorrentes, no dia 5 de setembro de 2016. Para o efeito todos os concorrentes foram notificados da proposta de decisão.

Nos termos do n.º 2 do art.º 148º, do CCP, elabora-se o presente Relatório Final, que considera a única pronúncia apresentada durante o período reservado à audiência prévia, pelo concorrente "Freitas Costa & Filhos, S.A.," (dia 12/09/2016, pelas 14h10m), em documento que se junta.

***

Relativamente às questões suscitadas pelo concorrente acima identificado, o Júri analisou e concluiu nos seguintes termos:

a. DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CONTEÚDO DO CADERNO DE ENCARGOS

No que respeita ao alegado pelo concorrente "Freitas Costa & Filhos, S.A." quanto à ilegalidade da Declaração de Aceitação do Conteúdo do Caderno de Encargos da empresa "Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda." (doravante Omatapalo), por alegada violação do disposto no n.º 4 do art.º 57 do CCP, o Júri considera o seguinte:

- o artigo 57.º n.º 4 do CCP exige que a declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos seja "assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poder para o obrigar";

- por sua vez, estabelece o art.º 7.º do Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 02 de agosto, atualizado, que "a aposição de uma assinatura digital a um documento eletrónico ou a uma cópia deste equivela à assinatura autógrafa dos documentos com forma escrita (...)";

- a declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos apresentada pela empresa "Omatopalo", contém a assinatura autógrafa de um gerente apenas, é certo, mas encontra-se **assinada eletronicamente pela sociedade** - com recurso a um certificado digital qualificado da pessoa coletiva "Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda";

- ou seja, entendeu o Júri que essa declaração foi assinada digitalmente por quem tem poderes para vincular a concorrente (assinatura digital qualificada da sociedade) à proposta apresentada e que traduz a aceitação do conteúdo do caderno de encargos;

- lembra o Júri que o documento em apreço não foi assinado digitalmente por um terceiro (ao contrário do que é referido no ponto 16 da pronúncia da concorrente, da qual parece resultar que o documento foi assinado digitalmente com recurso ao certificado de um dos gerentes, o que não corresponde aos factos verificados), mas sim pela própria pessoa coletiva "Omatapalo", que fez uso do seu certificado digital qualificado; deste modo, com o devido respeito e salvo melhor opinião, não estamos perante uma situação semelhante às que foram objeto dos acórdãos citados pela concorrente - em que são discutidas questões relacionadas com as diferenças entre os poderes de representação para submissão de documentos na plataforma e os poderes de vinculação (poder de obrigar) -

- veja-se, aliás, a este propósito, a jurisprudência do STA no proc. 01056/11, em acórdão de 08/03/2012, (www.dgsi.pt), que não deixa quaisquer dúvidas quanto à desmaterialização dos procedimentos e à relevância da assinatura eletrónica nesta matéria. Nele pode ler-se que "(...) *a apresentação da proposta (e documentos anexos) no âmbito do procedimento concursal desenvolvido sob a égide de Plataforma eletrónica tem de ser produzida por meio de transmissão eletrónica e a sua assinatura deve ser feita eletronicamente (...)*". Relativamente à assinatura eletrónica acrescenta ainda que "*a assinatura constitui a forma de vinculação dos concorrentes às propostas e documentos apresentados, sendo uma condição de validade das mesmas (...)*" (sublinhados nossos).

- pelas semelhanças com a situação em análise, cabe ainda invocar o entendimento do Tribunal Central Administrativo Norte, em acórdão de 25/11/2011, proc. 02389/10.4BELSB (www.dgsi.pt), que confirmou a decisão da 1.ª instância, nos termos seguintes:

"(...) V. A declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao CCP, enquanto documento que integrante das peças da candidatura/proposta apresentada no procedimento concursal, deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar [art. 57.º, n.ºs 1, al. a) e 4 do CCP], sendo causa de exclusão da proposta a sua ausência [art. 146.º, n.º 2, als. d) e e) do CCP], consubstanciando-se esta, nomeadamente, nas situações não apenas de falta absoluta ou física da mesma declaração do processo concursal mas

também das situações de junção da declaração sem assinatura nos termos legalmente exigidos.

VI. Não deriva, todavia, do regime normativo convocado, mormente e em especial, dos arts. 57.º, n.ºs 1, al. a) e 4 e 146.º, n.º 2, als. d) e e)ambos do CCP, que a assinatura da declaração em questão haja ou tenha de ser manual ou digitalizada para que se mostre cumprida ou observada a exigência neles feita em termos de assinatura, porquanto tais preceitos carecem de ser concatenados com o demais quadro aplicável e que disciplina os procedimentos concursais nas plataformas electrónicas, sendo que à luz daquele a exigência de assinatura pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar da declaração referida na al. a) do n.º 1 do art. 57.º do CCP deve ser feita por referência à assinatura electrónica tal como a mesma se mostra disciplinada e regulada pelo DL n.º 143-A/08 e pela Portaria n.º 701-G/08.

*VII. **Daí que a assinatura ali prevista e exigida não será a assinatura manual ou digitalizada mas ao invés a assinatura electrónica,** na certeza de que se o certificado qualificado da assinatura electrónica for emitido em nome duma pessoa colectiva já não será necessário juntar o documento a que se refere o n.º 3 do art. 27.º da Portaria n.º 701-G/08.*
(...)

*IX. Com efeito, pese embora a declaração em crise não se mostrar assinada manualmente, nem o documento contém assinatura que tivesse sido digitalizada, o que se comprova e se constata é que **o documento em questão foi submetido à plataforma electrónica e foi devidamente assinado pela A., enquanto ente colectivo, através de assinatura feita electronicamente ao abrigo de certificado qualificado emitido em seu nome e do qual deriva inequivocamente a função e poder de assinatura de quem o apôs e obriga, na certeza de que tanto basta para a total perfeição e validade do compromisso assumido em termos da declaração exigida pela al. a) do n.º 1 do art. 57.º do CCP. (...)"*** (negrito e sublinhado nossos)

Face a tudo o que vimos de aduzir, uma vez que a declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos do concorrente "Omatapalo", apesar de se encontrar manualmente assinada apenas por um gerente, foi assinada digitalmente por quem tem poderes para a obrigar – assinatura eletrónica da própria pessoa coletiva -, o Júri não tem quaisquer dúvidas quanto à vinculação da sociedade em tal documento (bem como, refira-se, em qualquer outro da proposta), dada a validade e relevância preponderante da assinatura eletrónica qualificada.

Assim, entende, salvo melhor opinião, que seria ilegal o ato de exclusão daquela proposta com o fundamento alegado na pronúncia em análise.

b. DECLARAÇÃO DE PREÇOS PARCIAIS DOS TRABALHOS A EXECUTAR E HABILITAÇÕES APRESENTADAS

Alega a concorrente na sua pronúncia que a empresa "Omatapalo" não demonstra possuir alvará para a 6.º subcategoria da 2.ª categoria e para a 5.ª subcategoria da 4.ª categoria, o que implicaria a insusceptibilidade de ver a sua proposta admitida.

Relativamente a esta questão, o Júri confirmou que o concorrente Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda. apresentou a declaração que refere a classe da 5.ª subcategoria da 1.ª categoria, cobrindo o valor global da obra e ainda uma declaração conjunta com subempreiteiro para os restantes trabalhos, constatando-se que, efetivamente, não foi apresentada declaração/alvará que demonstre habilitação para a 6.º subcategoria da 2.ª categoria (a 5.ª subcategoria da 4.ª categoria consta dos alvarás apresentados).

Estabelece-se no n.º 4 do art. 60ºdo CCP que, em caso de procedimento de formação de contrato de empreitada, o concorrente deve indicar na proposta os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás, para efeitos da verificação da conformidade desses preços com a classe das respetivas habilitações.

Como pode ler-se em Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, processo 0795/10, de 04/11/2010, disponível em www.dgsi.pt, *"A não apresentação de um alvará exigido no programa de concurso como necessário à boa execução da obra não pode, por si só, determinar a exclusão preliminar de um concorrente sem análise da respetiva proposta, pois que só em sede de habilitação de adjudicatário está prevista a obrigatoriedade dessa apresentação (...)."*

E acrescenta ainda que*" (...) o regime de apresentação dos documentos de habilitação do adjudicatário, concretamente dos alvarás exigidos no programa de concurso, pelo concorrente escolhido ou por subcontratado e da sua permitida substituição por declaração emitida pelo Instituto da Construção e do Imobiliário, IP, é o constante do* **art.º 81.º do CCP**, *preceito inserido na fase de habilitação do adjudicatário e que conforta com toda a clareza a tese de que a eventual irregularidade do alvará apresentado com a proposta não é, só por si, causa de exclusão preliminar do concorrente ou da respetiva proposta.(...)"*(sublinhado e negrito nossos*).*

Em concreto, relativamente à declaração de preços parciais nos termos do n.º 4 do art.º 60.º, o mesmo STA pronunciou-se, em acórdão de 01/10/2015, proc. 0856/15 (www.dgsi.pt), nos seguintes termos:

"(...)o objectivo visado pelo nº 4 do art. 60º do CCP, que é o de permitir à entidade adjudicante, perante os documentos que o adjudicatário apresente em cumprimento daquele art. 81º, avaliar se este tem, ou não, as habilitações necessárias à execução da obra(...)"

Além disso, conclui que:

"(...)Não se reportando a declaração prevista no art. 60º, nº 4 do CCP, a um verdadeiro atributo da proposta a considerar na respectiva avaliação e decisão de adjudicação, conforme os respectivos critérios, o CCP não contempla qualquer preceito que determine a exclusão da proposta por falta da indicação do referido elemento(...)."

Não pode o Júri deixar de lembrar que, em sede de habilitação, nos termos do disposto no art.º 81.º do CCP, o adjudicatário obrigatoriamente terá de apresentar os alvarás ou os títulos de registo emitidos pelo Instituto da construção e do Imobiliário, I.P., contendo as habilitações adequadas e necessárias à execução da obra a realizar, bem como, se for o caso, os alvarás ou os títulos de registo de titularidade de subcontratos, que serão acompanhados de declaração através da qual se comprometem, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às habilitações deles constantes.

Sublinha-se ainda que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 86.º do CCP, a falta de apresentação dos alvarás/títulos de registo, enquanto documentos de habilitação – e nessa "fase" do procedimento -, constitui causa legal de caducidade da adjudicação.

Assim e em conclusão, os elementos apresentados na proposta pelo concorrente "Omatopalo" permitem que, em sede de habilitação, seja facilmente verificada a adequação dos alvarás e das respetivas classes aos trabalhos de construção a realizar e que o contrato seja celebrado com a certeza de que o concorrente detém os alvarás necessários à execução dos trabalhos de construção civil envolvidos.

Perante o exposto, o Júri considera que seria manifestamente ilegal a exclusão da concorrente "Omatapalo" pelo motivo ora em análise.

c. ASSINATURA ELETRÓNICA DO ALVARÁ

Invoca a concorrente na sua pronúncia que os documentos da proposta apresentada pela "Omatapalo" não estão assinados com recurso a assinatura eletrónica qualificada, nomeadamente os alvarás.

Ora, o Júri confirmou que todos os documentos que constituem a proposta do concorrente "Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda." se encontram assinados digitalmente com recurso a uma assinatura eletrónica qualificada da sociedade, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto.

Salienta-se que os alvarás não são documentos de entrega obrigatória na fase de apresentação de propostas, (veja-se o Acórdão do STA, processo 0795/10, de 04/11/2010, citado acima) mas sim na fase de habilitação (artigo 81.º do CCP) e que, por isso, a exclusão de uma proposta por não conter assinatura eletrónica qualificada em tais documentos seria ilegal e traduziria, salvo melhor opinião, uma incorreta aplicação das disposições legais.

d. LISTA DE PREÇOS UNITÁRIOS

Relativamente ao alegado quanto à correção, pelo Júri, de uma quantidade (aumentando-a e consequentemente o preço) de um item na Lista de preços unitários apresentada pelo "Omatapalo", começa o Júri por lembrar a posição explanada no Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2010, de 19/01/2010, Uniformização de Jurisprudência, DR, 1ª série, , n.º32, 16/02/2010, onde pode ler-se que: "(...) Parece-nos ser este, pois, o entendimento mais

correto a dar, em abstrato, e em geral, à questão da repercussão da omissão de um preço ou de um item na lista de preços unitários, na proposta e às respetivas consequências jurídicas: a falta referida *não constitui, necessariamente, a omissão de um elemento essencial do procedimento que, só por si, possa afetar inexoravelmente a proposta e acarretar a sua exclusão.(...)"*

Acrescentando ainda:

"(...)Do mesmo modo, ***a correção da proposta****, para supressão dessa falta, constitui circunstância que* ***não*** **ofende os princípios a que deve subordinar-se a contratação pública** (...)"(negrito nosso)

Mais recentemente, o mesmo Tribunal de Contas, no Acórdão N.º 18/2015, de 1 de dezembro – 1.ª Secção/SS, proc. 1783/2015 (www.tcontas.pt) afirma:

"É certo que a ***possibilidade de correção de erros de cálculo ou de escrita, desde que ostensivamente relevados no próprio contexto da proposta, é uma excepção ao princípio da intangibilidade das propostas*** *[neste sentido, Rodrigo Esteves de Oliveira, «Os Princípios Gerais da Contratação Pública» in Pedro Gonçalves (org.) Estudos da Contratação Pública, I, Coimbra, 2008, p.76 e, no mesmo sentido, Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e outros procedimentos de contratação pública, cit., p. 213]."*(sublinhado e negrito nossos)

Também o Tribunal Central Administrativo Norte, em acórdão de 06/12/2013, proc. 02363/12.6BELSB, afirma: *"Tem-se como admissível que a entidade adjudicante proceda à correção ou consideração oficiosa de propostas de concorrentes admitindo a sanação de correções de pormenor ou a retificação de erros manifestos, de cálculo, de escrita ou outros constantes da proposta, nos termos do art.º 249.º do CC, sem exigir para o efeito, quer o consentimento prévio, quer o assentimento posterior por parte dos respetivos concorrentes.* (...)".

É que *"(...)a singela retificação de um erro evidente – sabendo-se o que devia estar na vez da declaração errada – não contende com a estabilidade das propostas, nem afeta a concorrência(...)". Com efeito, corrigir um lapso é colocar "in situ" o que se sabe que lá estaria "ab initio", não fora o erro cometido. E desde que o processo retificador se faça com plena segurança, o seu resultado nenhuma inovação traz – a não ser no que toca à supressão da anomalia; pois, e no fim de contas, limita-se a restituir o escrito, v.g. a proposta, à sua verdade original. (...)"*, como se lê no acórdão do STA de 20/06/2013, proc. 0467/13, www. dgsi.pt.

Ora, perante tal posição doutrinal e jurisprudencial, o Júri considera que a exclusão inexorável de uma proposta, por um evidente e notório lapso na quantidade de um item, revelado no contexto da proposta e para o qual é apresentado o respetivo preço unitário (ou seja, um erro facilmente sanável mediante simples operação de cálculo, que oficiosamente se realizou) se mostraria, em concreto, desnecessária, desadequada e desproporcionada – e suscetível de

acarretar prejuízo para o interesse público inerente à manutenção, em concurso, do maior número de candidatos e propostas.

Tal entendimento - e a sua concreta aplicação ao caso em apreço – assegura, em nossa opinião, a salvaguarda o princípio da igualdade (dada a sua aplicabilidade a todos os concorrentes), o princípio da transparência (uma vez que foi dado conhecimento a todos os concorrentes da correção de €67,19 no valor final de €1 789 121,44), o princípio da imparcialidade (a correção não colocou a proposta do concorrente em favorecimento relativamente aos outros), o princípio da concorrência (ficou salvaguardado o mais amplo acesso ao procedimento pelos interessados em contratar), o princípio da estabilidade ou da imutabilidade das propostas (uma vez que não foi alterada a substância e a essência da proposta – atente-se na diminuta relevância do elemento corrigido, bem como na insuscetibilidade de inviabilizar a análise comparativa das propostas ou de interferir na boa execução do contrato), o princípio da prossecução do interesse público (já que, com maior número de propostas, a entidade adjudicante está mais habilitada a efetuar uma melhor escolha entre estas).

Conclui-se, portanto, não ser de excluir a proposta da "Omatapalo" com este fundamento.

e. PRAZO DE EXECUÇÃO

No que respeita ao alegado na pronúncia quanto ao prazo de execução dos trabalhos da empreitada por parte da "Omatapalo", com o devido respeito, o Júri entende que a leitura atenta e conjugada dos elementos que integram a proposta não permite considerar razoável a conclusão de que a concorrente planeia (ou sequer revela qualquer indício no sentido de) executar os trabalhos num prazo superior ao estipulado no caderno de encargos (420 dias). Senão vejamos:

- no plano de trabalhos, o concreto planeamento, escalonamento, cálculo e dimensionamento das tarefas encontra-se efetuado para 14 meses (420/30 dias = 14 meses);

- igualmente são previstos 14 meses para a execução no plano de pagamentos, no plano de mão de obra, no plano de equipamentos e no cronograma financeiro;

- a memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra claramente assume a execução da obra no prazo de 420 dias após a sua consignação: *"Prazo de execução (pag 8 e 9): "O estudo dos meios humanos e dos equipamentos disponíveis e necessários, a otimização dos mesmos, a observação rigorosa do local dos trabalhos, a experiência em obras deste género e a definição de uma estratégia coerente e exequível,* ***permitem-nos concluir ser possível realizar a Empreitada num prazo total de 420 Dias, contados a partir da data de consignação, conforme Caderno de Encargos.****(...)"; Faseamento da obra (pag. 19):* Trabalhos especificados- Os rendimentos apresentados nesta memória descritiva e plano de trabalhos, são rendimentos médios e não traduzem as reais capacidades de produção das equipas (frentes de trabalho) dimensionadas para cada atividade.Tal, deriva do facto das equipas (frentes de trabalho) não executarem os trabalhos de uma forma contínua, mas acuarem sob

as ordens da Fiscalização da obra, **de acordo com o planeamento e programação previstos (420 Dias) (...)"**; *"Escalonamento e calendarização das tarefas - O escalonamento e calendarização dos trabalhos, mencionadas no plano de trabalhos, têm por base a experiência acumulada em diversas obras da mesma natureza e complexidade, cumprindo-se as boas regras de construção e respeito pelo caderno de encargos. A duração de cada atividade é função do rendimento das equipas de trabalho e dos equipamentos destacados para a execução da empreitada, rendimentos já afetados de coeficientes de subprodução* ***de acordo com o prazo global de 420 dias fixado pelo dono da obra.*** *(...)"*.(negrito nosso)

Assim, o que é revelado no contexto de toda informação constante da proposta, face à inequivocidade dos restantes elementos que indicam o prazo de execução, é que, em termos substanciais e concretos, a execução da obra encontra-se claramente planeada para 14 meses (ou seja, 420 dias), sendo coerente com esse prazo a definição apresentada da sequência e dos prazos parciais de cada uma das espécies de trabalhos previstas.

Ou seja, lida na globalidade a proposta e todos os documentos/declarações dela integrantes, de modo algum se pode inferir objetivamente que o concorrente oferece um prazo maior do que o referido no caderno de encargos.

O facto de constar do cronograma como data de início 05/12/2016 e de fim 31/01/2018 - sabendo-se que tais datas carecem de qualquer significado declarativo, sendo nesta fase meramente indicativas de um programa de ação, dado que as datas efetivas e reais de início dos trabalhos estão dependentes da data em que o contrato começa a produzir efeitos, a qual, no momento da elaboração da proposta, não é conhecida - não permite automaticamente concluir pelo incumprimento do prazo de execução.

Numa atenta leitura do conteúdo da documentação, que se impõe ser feita pelo júri/entidade adjudicante na análise e avaliação das propostas (desde logo do próprio plano de trabalhos, no qual, além de expressamente ser indicado "prazo 420 dias", são apresentados 14 meses de execução nas colunas de discriminação dos trabalhos; além disso, é evidente que o concorrente procedeu à conversão da duração total dos trabalhos em 303 dias (duração expressamente referida), distribuindo-os, para efeitos de elaboração do cronograma, em dias úteis e iniciando a contagem numa data que é fictícia por natureza), tal cumprimento revela-se ter ocorrido.

Vejamos como se pronuncia o STA sobre esta questão do prazo de execução, em acórdão de 22/03/2011, proc. 1042/10):
"As propostas apresentadas pelos candidatos concorrentes no âmbito de um concurso público, constituindo declarações negociais, estão sujeitas a interpretação como qualquer declaração de vontade, sendo aplicáveis, na falta de disposição especial nesta matéria, os critérios interpretativos previstos no Código Civil para os negócios formais (art.º 238.º deste diploma)."
E acrescenta:
"(...)Foi com base nos documentos que compõem a proposta que se concluiu que o prazo de execução de 4 meses não foi "objetivamente" ultrapassado. Só não seria de admitir o prazo de

4 meses se ele não tivesse o mínimo de correspondência, embora imperfeita, com o texto dos respetivos documentos.(...)"

Deste modo, considera o júri que não existe, também aqui, fundamento para a exclusão da proposta do concorrente Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda, tendo em conta ainda que, como pode ler-se em anotação ao art.º 70.º em *CCP Anotado e Comentado*, Jorge Andrade da Silva, 5.ª ed., pag 232, *"(...)aqueles fundamentos de exclusão das propostas têm em princípio a ver com aspetos substanciais ou formais considerados essenciais e cuja falta ou incorreção, segundo a lei, obstam à sua apreciação e valoração e, por isso mesmo, são excluídas dessa operação. Segundo M. e R. Esteves de Oliveira, essencial seria a falta ou irregularidade que prejudicasse a igualdade entre os concorrentes ou a possibilidade da correta e imparcial comparação de uma com as outras propostas (...)".* (sublinhado nosso).

A aplicação do princípio da proporcionalidade que vincula a atuação administrativa com expressa previsão constitucional (art. 266.º, n.º 2 da CRP) e legal (art. 5.º, n.º 2 do CPA), sendo também um princípio geral de direito comunitário conduz à mesma conclusão de que o intervalo entre as datas meramente indicativas que constam do cronograma, só por si, não deve determinar a exclusão da proposta, uma vez que se conclui, através da análise conjugada dos elementos que instruíram a proposta, que o prazo de execução da obra não excede os 420 dias e assim cumpre o estabelecido no caderno de encargos, pelo que, com o devido respeito e salvo melhor opinião, seria manifestamente desproporcionada e desadequada a decisão de excluir a proposta, tal como pretende o concorrente "Freitas, Costa § Filhos, SA" na sua pronúncia.

f. PONTUAÇÃO DO PLANO DE TRABALHOS

No que respeita ao alegado quanto à pontuação atribuída ao plano de trabalhos e com os fundamentos que vimos de aduzir, o Júri entende que o concorrente "Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda. demonstra planear a execução dos trabalhos no prazo de 420 dias/14 meses.

Cabe ainda sublinhar que, ainda que o Júri considerasse a atribuição de 1 ponto ao plano de trabalhos da concorrente "Omatapalo", como sugere em hipótese a concorrente "Freitas Costa & Filhos, SA "na sua pronúncia (deixando, assim, de ter em conta na avaliação daquele plano o facto estarem nele presentes a maioria das atividades da obra, as respetivas quantidades e as relações de precedência – critérios de avaliação definidos para este subfactor e que foram aplicados a todas as propostas), tal não iria ter qualquer repercussão na ordenação final das propostas: a proposta da empresa "Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda." manter-se-ia em primeiro lugar para efeitos de adjudicação, com 40,84 pontos (acima dos 31,72 pontos da proposta do concorrente Freitas Costa & Filhos, S.A.).

***

Deste modo, com fundamento no exposto anteriormente neste relatório e no Relatório Preliminar, o Júri do Procedimento delibera por unanimidade, nos termos do nº 1 do art.º 148.º, do CCP, manter o teor e as conclusões do Relatório Preliminar e propor assim:

1. A exclusão da proposta do concorrente:
   a. **Luís Maurício G. G. Instalações Elétricas, Sociedade Unipessoal, Lda.**: alínea o) do artigo 146.º do CCP - alínea d) do n.º2 do artigo 70.º do CCP.

2. A seguinte ordenação das propostas para efeitos de adjudicação:

1.º Omatapalo – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda.	€ 1.789.121,44
2.º Freitas Costa & Filhos, SA	€ 1.789.054,24
3.º Costeira – Engenharia e Construção, SA	€ 1.898.783,67
4.º Tecnorém, SA	€ 2.007.786,33
5.º Teixeira, Pinto & Soares, S.A.	€ 1.982.761,30
6.º DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.	€ 2.099.953,00
7.º José Abreu Enes da Lage & Irmão, Unipessoal, Lda.	€ 2.080.000,00
8.º Alexandre Barbosa Borges, S.A.	€ 2.094.000,00
9.º Costa & Carreira, Lda.	€ 1.990.000,00

(Os valores das propostas não incluem o IVA à taxa em vigor)

3. A adjudicação do concurso público para a execução da referida empreitada, incida sobre a proposta do concorrente **Omatapalo – Engenharia e Construção unipessoal, Lda.**, pelo preço contratual de **€ 1.789.121,44** (um milhão setecentos e oitenta e nove mil cento e vinte e um euros e quarenta e quatro cêntimos), acrescido do IVA à taxa em vigor;

Paredes de Coura, 21 de setembro de 2016

O Júri do Procedimento,

(Marlene Sofia Vieira Castilho)

(Sofia Lages de Carvalho)

(Jorge Paulo Alvarenga Lages - suplente)

Exmo. Júri do Procedimento

Assunto: Procedimento por Concurso Público - Empreitada "*REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 E SECUNDÁRIA DE PAREDES DE COURA*" – **AUDIÊNCIA PRÉVIA**

FREITAS COSTA & FILHOS, S.A., (doravante, e de modo abreviado, apenas designada por "Signatária") Concorrente no Procedimento acima referenciado e nele melhor identificada, notificada que foi do Relatório Preliminar e não concordando com o seu teor, vem, ao abrigo do disposto nos artigos 147.º e 123.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), exercer o direito de audiência prévia, nos termos e com os fundamentos seguintes:

I – DA FACTUALIDADE ANTECEDENTE E ENQUADRAMENTO DA PRETENSÃO:

1. Pelo Município de Paredes de Coura foi promovido o Concurso Público para a execução da empreitada designada por "*REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 E SECUNDÁRIA DE PAREDES DE COURA*".

2. Ato contínuo a Signatária apresentou a sua competente proposta, de forma séria e cuidada, por forma a satisfazer o Interesse Público inerente à Empreitada, respondendo a todas as exigências do Dono de Obra e pelo melhor preço possível.

3. Finalizada a instrução da fase procedimental respeitante à análise e à avaliação das Propostas, o Exmo. Júri elaborou o Relatório Preliminar, concluindo com a ordenação em 1.º lugar da proposta

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

apresentada pelo concorrente **OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA.** (doravante e de modo abreviado **OMATAPALO**).

4. Sendo a proposta da Signatária relegada para segundo posto.

5. Sucede que, por mais respeito que nos mereça o Exmo. Júri e a Entidade Adjudicante – que é muito – não pode a Signatária, de forma alguma, concordar com o teor do Relatório Preliminar, o que motiva a presente pronúncia.

6. Na verdade, entende a Signatária, porque é evidente, que o Relatório Preliminar elaborado pelo Exmo. Júri suscita reservas jurídicas da maior relevância, nomeadamente quanto à admissão e graduação no primeiro posto da proposta da **OMATAPALO** as quais podem agrupar-se em torno de quatro tópicos principais e inquinam todo o procedimento:

   - ✓ Exclusão da proposta da concorrente **OMATAPALO**, nos termos do disposto nos artigos 57.º, n.º1, alínea a) e n.º4, e 146.º, n.º2, alínea d), ambos do CCP;
   - ✓ Violação do disposto no artigo 60.º, n.º 4, do CCP, culminado com a sanção de não admissão/exclusão, nos termos do disposto no artigo 12.º, do Programa de Procedimento;
   - ✓ Exclusão da proposta da **OMATAPALO**, por violação de termos ou condições não submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos;
   - ✓ Errónea avaliação da proposta no subfator "Plano de Trabalhos;

Vejamos então,

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

A – <u>DA EXCLUSÃO DA PROPOSTA DA OMATAPALO POR VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 57.º, N.º 4, DO CCP</u>:

7. Ora, a concorrente **OMATAPALO**, em ordem a cumprir o que é preceituado no artigo 57.º, n.º1, alínea a), do CCP, juntou "Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos" na qual o Senhor **JOSÉ ABÍLIO DA SILVA MENESES**, na qualidade de representante legal da sociedade, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas,

8. E, de forma isolada e singular, assina.

9. Sucede que, o Sr. José Abílio da Silva Meneses, **<u>não tem poderes para, por si só e individualmente</u>**, vincular a **OMATAPALO**, porquanto, a forma de obrigar a sociedade, tal como resulta da consulta da certidão permanente, faz-se com intervenção de **<u>dois gerentes</u>**.

10. Ou seja, a gerência da **OMATAPALO** é exercida pelos Senhores **JOSÉ ABÍLIO DA SILVA MENESES**, **CARLOS SOARES ALVES** e **FILIPE OSÓRIO DE SOUSA FELGUEIRAS LOPES**, e a sociedade obrigava-se perante terceiros pela assinatura conjunta de dois gerentes.

.

11. Ora, o artigo 57º nº1 alínea a) do CCP diz que, a proposta é constituída pelos seguintes documentos: a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo I ao presente código, do qual faz parte integrante […], e o n.º4 do mesmo artigo diz que essa declaração de aceitação deve ser assinada pelo concorrente (pessoa singular) ou por representante (pessoa coletiva) **<u>que tenha poderes para o obrigar</u>**,

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

12. Ora, no caso, apesar da dita "Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos" ter sido submetida e assinada eletronicamente, esta apenas se encontra assinada por um dos Gerentes,

13. Sendo que, *"A declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, além de dever ser assinada digitalmente por pessoa com poderes para a submeter electronicamente na plataforma,* ***também tem de ser assinada por quem tem poderes para vincular o concorrente***"[1] (negrito e sublinhado nossos).

14. Isto porque, *"Distinta desta assinatura digital de todos os documentos, necessária para os carregar na plataforma electrónica, é a assinatura da declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, prevista na alínea a) do n.º1 do art. 57.º do CCP,* ***indispensável à enunciação da vontade de contratar e que tem de provir de quem tem poderes para obrigar o concorrente***"[2] (negrito e sublinhado nossos).

15. No caso em apreço, a proposta apresentada pela **OMATAPALO** integrou a declaração a que alude o mencionado artigo 57.º, n.º 1, al.a), do CCP, onde se referia que o Sr. **JOSÉ ABÍLIO DA SILVA MENESES**, na qualidade de representante legal daquela, declarava, sob compromisso de honra, que se obrigava a executar o contrato em conformidade com o conteúdo do caderno de encargos.

16. Sendo que, o Certificado Digital de assinatura eletrónica encontra-se associado, também ele, ao Sr. **JOSÉ ABÍLIO DA SILVA MENESES**.

[1] Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido no processo n.º 054/15, de 10/09/2015, disponível em www.dgsi.pt.
[2] Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido no processo n.º 040/14, de 09/04/2014, disponível em www.dgsi.pt.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

17. Ora, a **OMATAPALO**, como sociedade por quotas, tem os seus Gerentes como representantes legais, que a obrigam perante terceiros apondo a sua assinatura, com a indicação dessa qualidade (cf. artigo 260.º, n.º 4 do CSC).

18. Sucede que, no caso concreto, a vinculação da sociedade depende da assinatura de dois dos gerentes.

19. Compulsada a proposta da **OMATAPALO**, constata-se esta apenas se encontra assinada por um dos gerentes, logo, sem os poderes bastantes para vincular a sociedade.

20. Nesta conformidade, o júri do concurso no relatório preliminar estava vinculado a propor a exclusão de uma proposta instruída nestes termos.

21. *"A referência, nos arts. 146º, nº. 2, al. e) e 57º, nº. 4, ambos do CCP, a um dever jurídico de, no relatório preliminar, se propor a exclusão da proposta, demonstra que os requisitos exigidos têm de estar cumpridos aquando da elaboração desse relatório e que, detectada a falta, o júri fica vinculado a propor e o órgão adjudicante a decretar, tal exclusão, não existindo, assim, neste âmbito, qualquer margem de livre apreciação por parte desses órgãos"*[3].

22. Pelo que, não sendo proposta a exclusão da proposta da concorrente **OMATAPALO** ocorreu uma violação irremediável dos artigos 57.º, n.º1, alínea a) e n.º4, e 146.º, n.º2, alínea d), ambos do CCP, o que inquina o procedimento de ilegalidade.

23. O que se invoca para todos os efeitos legais.

[3] Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido no processo n.º 054/15, de 10/09/2015, disponível em www.dgsi.pt.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt

Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

24. Devendo, por isso, ser excluída uma proposta assim instruída.

Sem prescindir,

B – <u>DA EXCLUSÃO DA PROPOSTA DA OMATAPALO POR VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 60.º, N.º 4, DO CCP, E ARTIGO 12.º DO PROGRAMA DO PROCEDIMENTO</u>:

25. Nos termos do disposto no artigo 12.º, do Programa de Procedimento (PP) *"Para admissão ao concurso é necessário possuir as seguintes categorias e subcategorias de acordo com a Lei n.º 41/2015, de 3 de junho: a 5ª subcategoria da 1ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta e as* ***6ª subcategoria da 2ª categoria****,* ***5ª subcategoria da 4ª categoria****, 9ª subcategoria da 4º categoria, 10ª subcategoria da 4ª categoria e a 12ª subcategoria da 4ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem"* (negrito nosso).

26. Sendo que, nos termos do disposto no artigo **14.º, n.º 3, do PP** era documento da proposta *"Declaração onde o concorrente indica os preços parciais dos trabalhos que se propõe executar correspondentes às habilitações contidas nos alvarás ou nos títulos de registo, de acordo com o n.º 4 do artigo 60.º do CCP"*.

27. Ora, compulsada a proposta da Concorrente **OMATAPALO**, são várias as faltas que se lhe aponta e que são motivo de exclusão,

Senão vejamos,

28. Desde logo, a declaração submetida nos termos do disposto do artigo 14.º, n.º 3, do PP e 60.º, n.º 4, do CCP, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 12.º, do PP, não permite ao Júri ou à entidade adjudicante atingir os objetivos visados pelas disposições regulamentares.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt

Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

29. Na verdade, de todos os documentos submetidos (ainda que de forma irregular, como se demonstrará), não resulta que a **OMATAPALO**, ou qualquer subcontratado, possua alvará que permita cumprir com os requisitos exigidos, nomeadamente, a 6.ª Subcategoria (SANEAMENTO BÁSICO), da 2.ª Categoria (VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRAESTRUTURAS),

30. Bem como, não possui e não entregou, alvará que permita executar trabalhos relativos à 5.ª Subcategoria (REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TENSÃO DE SERVIÇO ACIMA DE 30 KV) da 4.ª Categoria (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS).

31. Pelo que, face à redação do artigo 12.º, do PP, *"Para admissão ao concurso é necessário possuir as seguintes categorias e subcategorias"*, não resta senão concluir pela exclusão da proposta da **OMATAPALO** por não demonstrar ser detentora de alvará necessário.

32. Aliás, de todos os documentos submetidos, antes resulta que não possui alvará para a 6.ª Subcategoria (SANEAMENTO BÁSICO), da 2.ª Categoria (VIAS DE COMUNICAÇÃO, OBRAS DE URBANIZAÇÃO E OUTRAS INFRAESTRUTURAS), bem como, para a 5.ª Subcategoria (REDES E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TENSÃO DE SERVIÇO ACIMA DE 30 KV) da 4.ª Categoria (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS).

33. O que implica a insusceptibilidade de ver a sua proposta admitida e avaliada no presente procedimento.

34. O que se invoca para os devidos efeitos legais.

Sem prescindir,

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt

Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

35. Do mesmo modo, ao invés de ser proposta a adjudicação da Empreitada ao concorrente **OMATAPALO**, deveria este ter sido excluído nos termos das disposições conjugadas dos artigos 62.º e 146.º, n.º 2, alínea l), do CCP, por violação do disposto no artigo 54.º, n.ºs, 1, 2 e 5, da Lei n.º 96/2015, de 17 de Agosto.

36. Nomeadamente por não ter aposto **Assinatura Eletrónica Qualificada** em todos os documentos da proposta.

Senão vejamos,

37. Os artigos 62.º e 146.º, nº 2, alínea l), do CCP e, em sua concretização, o D.L. nº 143-A/2008, de 25/07 e a Portaria nº 701-G/2008, de 29/07, (**entretanto revogados pela Lei n.º 96/2015**, de 17 de Agosto) manifestaram a opção clara do legislador nacional pela desmaterialização integral dos procedimentos relativos à formação e celebração dos Contratos Públicos.

38. Ou, por outras palavras, pela contratação pública eletrónica, baseada na utilização de tecnologias, designadamente, pela utilização de plataformas eletrónicas por parte de todos intervenientes nos procedimentos.

39. Ora, do citado regime legal resulta que, a apresentação de propostas se faz diretamente na plataforma eletrónica da entidade adjudicante e que, sobre as propostas – e todos os documentos que as compõem – deve recair uma assinatura eletrónica qualificada, de acordo com exigências legais e regulamentares que, além de específicas, são **imperativas**.

40. Prevendo a lei, como efeito jurídico associado ao incumprimento das formalidades previstas para a apresentação das propostas, a sua exclusão liminar.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

41. Como resulta da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto (que regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública e transpôs o artigo 29.º da Diretiva 2014/23/UE, o artigo 22.º e o anexo IV da Diretiva 2014/24/UE e o artigo 40.º e o anexo V da Diretiva 2014/25/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, revogando o Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de julho), nomeadamente no Artigo 54.º, da Lei 96/2015, de 17 de Agosto, sob a epígrafe ***ASSINATURAS ELECTRÓNICAS*** dispõe o n.º 1 que, *"Os documentos submetidos na plataforma eletrónica, pelas entidades adjudicantes e pelos operadores económicos, devem ser assinados com recurso a assinatura eletrónica qualificada, nos termos dos n.os 2 a 6"*.

42. Segue o n.º 2, do referido artigo 54.º referindo que, *"Os documentos elaborados ou preenchidos pelas entidades adjudicantes ou pelos operadores económicos devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais"*.

43. Compulsada a proposta da **OMATAPALO** constata-se que esta não assinou, com recurso a assinatura eletrónica qualificada, todos os documentos da proposta,

44. Nomeadamente, o **ALVARÁ**.

45. E, também, o Alvará da **LUÍS MAURÍCIO GIESTAS GONÇALVES INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.**, sua eventual subcontratada.

46. O que implica a sua exclusão nos termos das disposições conjugadas dos artigos 62.º e 146.º, n.º 2, alínea l), do CCP, por violação do disposto no artigo 54.º, n.ºs, 1, 2, da Lei n.º 96/2015, de 17 de Agosto.

Sem prescindir,

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

C - <u>DA EXCLUSÃO DA PROPOSTA DA OMATAPALO POR VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 70.º, N.º 2, ALÍNEA B), DO CCP</u>:

47. Vem referido no Relatório Preliminar, para o que aqui nos ocupa que:

> Informa-se que foram verificadas **as Listas de Preços Unitários (alínea b)** do n.º 1 do artigo 14.º do Programa de Procedimento) apresentadas pelos concorrentes e verificou-se que a Lista do concorrente OMATAPALO – Engenharia e Construção Unipessoal, Lda. apresentava uma quantidade errada (20ml) no artigo II-3.3.2.1.2.1 sendo a correta 30ml. Uma vez que foi apresentado preço para esse artigo apenas se procedeu à correção do valor total para **esse** artigo e por consequência do valor total da empreitada.

(Fig. 1 – Relatório Preliminar)

48. Ora, desde logo, não se pode aceitar, por ser manifestamente ilegal, a correção oficiosa de propostas de preço pelo Exmo. Júri.

49. Na verdade, a alteração assim operada pelo Exmo. Júri alterou o preço da proposta, logo, violou, entre outros, o Princípio da Intangibilidade que tão caro é em matéria de contratação pública.

50. Na verdade, e como é sabido, de acordo com o disposto no artigo 56.º, n.º 1 do Código da Contratação Pública (CCP) a proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta a vontade de contratar e o modo como se dispõe a fazê-lo.

51. Embora *"pareça inferir-se que a proposta se traduz apenas numa declaração de vontade de contratar, do n.º 1, do artigo 56.º resulta claro que a proposta é bem mais que isso, pois que, por um lado, deve ser integrada por uma declaração inequívoca de vontade de contratar* ***<u>nos termos e condições constantes do caderno de encargos</u>*** *(…) e, por outro, engloba ainda: os documentos relativos aos atributos da proposta, isto é,* ***<u>o modo como se dispõe a contratar os aspetos</u>***

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

submetidos à concorrência no programa de procedimento e no caderno de encargos *(…)"*[4] (negrito e sublinhado nossos).

52. Ora, sendo o preço um atributo da proposta, submetido à concorrência pelo Caderno de Encargos, é, também, sobre este que incide a avaliação da mesma, é o preço que permite que a proposta apresentada se singularize das demais,

53. Ou seja, tendo a **OMATAPALO** declarado, expressa e inequivocamente, que se dispunha a contratar pelo preço global de **1.789.054,25€ (um milhão setecentos e oitenta e nove mil cinquenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos)**, não era legítimo, ao Exmo. Júri, alterar a declaração de vontade do Concorrente.

54. Ou seja, o Exmo. Júri, para além de alterar a declaração negocial da **OMATAPALO**, alterou um atributo da proposta, violando o princípio da intangibilidade.

55. O que consubstancia um vício de violação de lei que acarreta a anulabilidade de todo o procedimento e do ato de adjudicação, caso venha a ser praticado a favor da proposta prevaricadora.

56. Em suma, de forma ilegítima e ilegal, foi operada, oficiosamente, uma correção do preço contratual proposto pela **OMATAPALO** pelo Júri, contrariando a declaração negocial desta e, acima de tudo, violando o princípio da intangibilidade das propostas.

[4] JORGE ANDRADE DA SILVA, *in "Código do Contratos Públicos, Anotado e Comentado, 2013, Almedina, pág. 197.*

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

57. Do mesmo modo, de nada vale o erro detetado na lista de preços unitários, porquanto tal como a Signatária, todos os concorrentes estavam em posição de cumprir com aquilo que vinha exigido.

58. De resto, e por não ter cumprido com aquilo que vinha exigido no Caderno de Encargos e subtraído à concorrência, deveria a proposta da **OMATAPALO** ter sido excluída (artigo 70.º n.º 2, b), do CCP).

59. O que se invoca para os devidos efeitos legais.

60. Na verdade, o efeito jurídico sancionatório consagrado no artigo 70.º n.º 2, b), do CCP decorrente da **violação de aspetos de execução do contrato subtraídos à concorrência** mas descritos e, portanto, regulados no caderno de encargos, é explicável em via de coerência com a natureza jurídica que esta peça do procedimento assume no modo de formação dos preceitos negociais que vão exteriorizar o comportamento negocial declarativo das partes, nos termos gerais da teoria do negócio jurídico.

61. De facto, o caderno de encargos constitui, sempre, parte integrante do contrato, a par dos esclarecimentos e retificações a ele respeitantes e dos esclarecimentos prestados pelo adjudicatário sobre a proposta adjudicada, cfr. artigo 96.º, n.º 2, als. b), c) e e), CCP.

62. O que significa que os termos ou condições são irrelevantes apenas do ponto de vista adjudicatório, mas não do ponto de vista do interesse público presente no objeto do contrato.

63. Como nos diz a doutrina especializada, *"atributo é algo adjudicatóriamente relevante e que o termo ou condição é adjudicatóriamente irrelevante e sabemos também que, apesar disso, ambos versam sobre aspectos tidos por relevantes para os interesses ou objectivos prosseguidos pela entidade adjudicante com o contrato em causa, pois, se não fosse assim, não se teria ela preocupado e*

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

pronunciado sobre os mesmos no caderno de encargos – donde qualificarmo-los como termos ou condições procedimentais" da proposta[5].

64. No tocante a estes aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência, o concorrente limita-se a aderir (por estarem estritamente definidos no caderno de encargos, não há qualquer atividade concretizadora por parte do concorrente) ou cuja concretização não é relevada ao nível adjudicatório (não há aí uma disputa entre os concorrentes).

65. Trata-se, portanto, de uma distinção que, mais do que atender à existência/inexistência de um labor do concorrente na concretização do projeto contratual contido no caderno de encargos, olha para a relevância/irrelevância dessa concretização para efeitos de escolha da melhor proposta[6].

66. Como dito, em razão desta relevância para o interesse público presente no objeto do contrato é cominada a exclusão das propostas que *"apresentem quaisquer termos ou condições que violem aspectos da execução do contrato a celebrar por aquele* [o caderno de encargos] *não submetidos à concorrência"* (70º nº 2 b), 2ª parte, CCP).

67. Ora, as quantidades de trabalho estão subtraídas à concorrência e vêm definidas no Caderno de Encargos,

68. Assim, e por ter proposto executar trabalhos com quantidades distintas das exigidas, a proposta da **OMATAPALO** violou o disposto no artigo 70.º, n.º 2, alínea b), 2ª parte, CCP, sendo cominada com a sanção de exclusão.

[5] Mário e Rodrigo Esteves de Oliveira, Concursos e Outros Procedimentos de Contratação Pública, pág. 588.
[6] Neste sentido mas por outras palavras, Luís Verde de Sousa, *in* A negociação nos procedimentos de adjudicação – uma análise do Código dos Contratos Públicos, Almedina/2010, pág.186.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

69. O que se invoca para os devidos efeitos legais.

Sem prescindir,

70. Do mesmo modo, se atentarmos no Plano de Trabalhos da **OMATAPALO**, constatamos que, o prazo por esta proposto para a execução dos trabalhos viola, também, o prazo imperativo e subtraído à concorrência pelo Caderno de Encargos.

Senão vejamos,

71. A **OMATAPALO** no seu Plano de Trabalhos estipula como data de início da execução dos trabalhos o dia **05 de Dezembro de 2016** e o seu término a **31 de Janeiro de 2018**.

72. Sendo, a partir dessa data de 05 de Dezembro de 2016 que se **calculam e verificam todas as datas e prazos subsequentes**.

73. Assim, desde logo podemos afirmar, porque resulta evidente, que o prazo de execução apresentado pela **OMATAPALO** no seu Plano de Trabalhos é de **423 dias** e não de 420, como imperativamente vem exigido nas peças patenteadas.

74. Note-se que, apesar de referir na MDJ o prazo de 420 dias, certo é que, o **concreto planeamento, escalonamento, cálculo e dimensionamento das tarefas encontra-se efetuado, sem margem para dúvidas, em 423 dias**.

75. Em suma, resulta por demais evidente que, a **OMATAPALO** no seu Plano de Trabalhos **previu, planeou, calculou e dimensionou as durações dos diversos trabalhos objeto da empreitada em 423 dias de calendário**.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

76. Assim, e por ter apresentado um prazo de 423 dias para a execução da empreitada, tal factualidade implica a exclusão da proposta da **OMATAPALO**, nos termos do disposto no artigo 70.º, n.º 2, alínea b), do CCP,

77. O que se invoca para todos os efeitos legais.

78. Do mesmo modo, e não obstante ser fundamento de exclusão a falta ora apontada à proposta da **OMATAPALO**, certo é que, ainda que assim não se entendesse – o que não se concede e apenas por mero exercício académico se concebe –, sempre seria fundamento para uma drástica redução na pontuação.

79. Quer no Plano de Trabalhos, quer nos restantes subfatores com este conexos.
Vejamos então,

D – DA ERRÓNEA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA:

80. Desde logo, é por demais evidente, com o recurso a uma simples operação aritmética que a **OMATAPALO** no Plano de Trabalhos que apresenta, viola o prazo imperativo de 420 dias,

81. Sendo que, como se disse, não obstante esta factualidade ser fundamento de exclusão, por violação de termos ou condições não submetidos à concorrência pelo Caderno de Encargos – por mera cautela – sempre será fundamento para uma drástica redução na pontuação obtida.

82. Com a agravante de que, em muito revela a errónea preparação e escalonamento das atividades da empreitada e que afetam a proposta como um todo.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

83. Na verdade, a própria MDJ teria de ser revista pelo Exmo. Júri, porquanto, não existe uma real compatibilização da mesma com o escalonamento e precedência das atividades.

Mas vejamos o Plano de Trabalhos,

84. Os critérios de avaliação vertidos no Programa de procedimento, para avaliação deste subfator prescrevem o seguinte:

Descrição	Pontuação
Não considera a maioria das atividades e/ou não indica a duração das mesmas, sem cumprir o prazo de execução estipulado no procedimento.	1 Ponto
Considera a maioria das atividades indicando a duração das mesmas, em cumprimento do prazo de execução estipulado no procedimento.	2 Pontos
Considera a maioria das atividades indicando a duração das mesmas, em cumprimento do prazo de execução estipulado no procedimento, as respetivas quantidades e as relações de precedência.	3 Pontos
Considera a maioria das atividades indicando a duração das mesmas, em cumprimento do prazo de execução estipulado no procedimento, as respetivas quantidades e as relações de precedência, identificando o caminho critico. Tem em conta as diferentes frentes e simultaneamente os equipamentos e mão-de-obra.	4 Pontos
Considera a maioria das atividades indicando a duração das mesmas, em cumprimento do prazo de execução estipulado no procedimento, as respetivas quantidades e as relações de precedência, identificando o caminho critico. Tem em conta as diferentes frentes e simultaneamente os equipamentos e mão-de-obra. Considera ainda um escalonamento de atividades que minimiza de forma evidente a utilização do equipamento.	5 Pontos

(Fig. 2 – Programa de Procedimento)

85. Ora, conforme resulta, com mediana evidência do Plano de Trabalhos da **OMATAPALO** esta propõe, escalona e dimensiona a execução das tarefas objeto da presente empreitada para um período de 423 dias.

86. Assim, atentos os critérios de avaliação, e por se tratar de um Plano de Trabalhos que foi elaborado *"sem cumprir o prazo de execução estipulado no procedimento"* nunca poderia ter a proposta da **OMATAPALO** ter obtido uma pontuação superior a 1 ponto, neste subfator.

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

87. O que se invoca para todos os efeitos legais.

88. Do mesmo modo, o escalonamento e calendarização da MDJ estará inquinado do mesmo vício ou, no limite, não será compatível com o Plano de Trabalhos, o que acarreta, também, uma drástica redução da pontuação obtida pela **OMATAPALO** neste subfator.

89. Contudo, e face a todas as ilegalidades apontadas à proposta da **OMATAPALO**, e salvo o devido respeito, não restará alternativa senão a de proceder à sua exclusão nos termos e com os fundamentos elencados ao longo da presente.

E) NOTA FINAL

§ Por último, cumpre informar que, caso no Relatório Final a realizar seja mantida a proposta de decisão, a signatária:

✓ Não obstante o respeito que nos merecem as *doutas* deliberações do Exmo. Júri do Procedimento, fica, no entanto, salvaguardada a possibilidade de vir a requerer a anulação do concurso por vício de violação de lei, por violar os princípios da legalidade, do formalismo/adequação procedimental, da concorrência, igualdade, da transparência, da imparcialidade, com o respetivo **efeito suspensivo automático do procedimento consagrado no novo artigo 103.º-A, do CPTA**.

Pelo que, nos termos *supra* expostos,

i) Deve ser anulado o Relatório Preliminar, tudo com as legais consequências;

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt
Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €

ii) Deve ser excluída a proposta do concorrente **OMATAPALO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA.**, nos termos expendidos na presente, tudo com as legais consequências;

iii) Deve ser elaborado novo Relatório Preliminar onde venha proposta a adjudicação à proposta da Signatária.

P.E.D.

A Signatária,

FREITAS COSTA E FILHOS SA

Digitally signed by FREITAS COSTA E FILHOS SA
DN: cn=FREITAS COSTA E FILHOS SA c=PT ou=Obs3 - MUNICIPIOS: L60/2007 e=financeiro@freitascosta.pt
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2016-09-12 09:39+01:00

Freitas Costa & Filhos, S.A.
A Administração

Rua do Cruzeiro, 254 • Maximinos • 4700-116 BRAGA • Telef. 253 606 830 • Fax 253 619 290 • E.mail: geral@freitascosta.pt

Contribuinte N.º 501 328 238 • Capital Social: 400.000,00 €